

1500653-76.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... que uma delas será utilizada como MAUS ANTECEDENTES, em decorrência da condenação por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, processo n.º 0008142-93.2014.8.26.0198, que tramitou perante a Vara Criminal de Franco da Rocha, com trânsito em julgado para a defesa em 15/12/2016, estando em cumprimento do livramento condicional, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

2ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1500653-76.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500653-76.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIANS FAGUNDES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

WILLIANS FAGUNDES, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I c.c. artigo 14, inciso II e artigo 180, "caput", na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, porque, em data e horário incertos, porém entre 10 de janeiro e 05 de março de 2022, na Av. das Indústrias, Bairro Benedito Storani, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com Cristiano Cavalheri Maria e Walisson Domingues da Silva, teriam adquirido e transportado, em proveito próprio, um molho de chaves especial, que sabiam ser produto de crime.

Consta ainda, que no dia 05 de março de 2022, na Av. das Indústrias, Bairro Benedito Storani, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com Cristiano Cavalheri Maria e Walisson Domingues da Silva, teria tentado subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 30 metros de cabos de energia e um rádio transmissor de telecomunicação, pertencente a empresa Claro S/A, sendo que seu intento apenas não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (pág. 192/193).

O réu WILLIANS constituiu advogado (pág. 190/191), foi citado (pág. 251/252) e apresentou defesa (pág. 227/229).

Na resposta à acusação, a Defesa do réu WILLIANS afirmou não haver provas de autoria. Pugnou pela prova pericial. Ao final, requereu a sua absolvição e arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

O representante do Ministério Público, considerando que não conseguiu ofertar os outros dois indivíduos o ANPP, ofereceu ADITAMENTO À DENÚNCIA, incluindo na presente ação os réus WALISSON DOMINGUES DA SILVA e CRISTIANO CAVALHERI MARIA (pág. 289/291).

O aditamento à denúncia foi recebido em 16 de maio de 2022 (pág. 306/307).

O réu WALISSON foi citado por EDITAL (pág. 397/399). Compareceu, nesta data, em Juízo, ofertando, também, defesa preliminar.

O réu CRISTIANO, habilitou-se nos autos e apresentou defesa (pág. 321/329).

Na resposta à acusação, a Defesa do réu CRISTIANO afirmou que ele não praticou o delito, o que será demonstrado no transcorrer da ação penal. Em sede de preliminar, alegou que a denúncia é inepta, bem como falta de justa causa, pugnando pelo trancamento da ação penal. No mérito, aduziu não haver provas para a condenação. Ao final, pugnou por sua absolvição.

Após, o réu WALISSON, habilitou-se nos autos (pág. 421/422).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, tendo, por fim, os réus WILLIANS, CRISTIANO e WALISSON sido interrogados.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se os réus nos termos da denúncia. Em seguida as Defesas pugnaram pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Com relação à ANPP, em favor do réu WALLISON, ciente das razões do Ministério Público.

Da Materialidade:

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 05), pelo boletim de ocorrência (pág. 25/29), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 30/31 e 32/34), pelo auto de avaliação (pág. 168), pelo Boletim de Ocorrência da subtração do molho de chaves (pág. 176/178, 179/181 e 182/184), pelo LAUDO PERICIAL dos OBJETOS APREENDIDOS (pág. 244/250), pelo LAUDO PERICIAL do LOCAL DOS FATOS (pág. 339/344), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, o réu WILLIANS FAGUNDES, assim relatou:

“QUE não foi agredido nem desrespeitado pelos responsáveis por sua prisão. Que vieram a cidade de Vinhedo a passeio; avistaram a fazenda com o portão aberto e adentraram para pegar milhos; que, ao tentarem sair, o portão estava trancado,

então tentaram sair por uma cerca e o carro atolou. Que era Cristiano quem dirigia o veículo Fox, o qual é propriedade de sua tia Solange. Nega subtração de qualquer item. Informa que, dentro do veículo havia roupas, chinelo, celular e sua carteira. Questionado sobre qual celular apreendido é o seu, respondeu que o Moto G9, com capa azul, e não deu autorização para que seja vasculhado". Em Juízo, declarou que em uma sexta feira estava com Cristiano e o Walisson bebendo. Saiu para uma balada com os corréus em Campinas. No dia seguinte, quando estavam retornando para casa, pararam em uma rua de terra para fazer necessidades. Encontraram uma porteira aberta, ao lado havia uma plantação de milho. Pegaram alguns milhos. Ao tentar sair, verificaram que o portão foi fechado. Tiraram a cerca e tentaram sair com o carro, que ficou preso no barranco. Nesse momento, foram abordados pelos policiais. Não havia material de cobre dentro do carro. É usuário de drogas.

Por sua vez, ainda na fase policial, o réu WALISSON DOMINGUES DA SILVA, assim informou:

"QUE não sofreu agressão nem foi desrespeitado pelos responsáveis por sua prisão. Sobre os fatos, que veio nesta cidade dar passeio; entraram em uma estrada de terra, viram uma porteira aberta, viram uma torre e entraram por curiosidade; que ouviram chamar e, ao tentar sair, o portão estava trancado. Quem estava dirigindo o veículo Fox era Cristiano, sendo o veículo da tia do Willians. Questionado sobre a roupa que está usando, informou ser seu uniforme de borracheiro. Nega ter subtraído qualquer item do local. Que, dentro do veículo, havia apenas um chinelo e uma bermuda". Em Juízo, declarou que não é verdade o que consta na denúncia. Saiu com o demais réus para Campinas e dormiram na casa de umas meninas. Na volta, pararam em uma rua para fazer necessidades. Visualizaram uma plantação de milho e foram pegar alguns. No retorno, o portão tinha sido trancado com cadeado. Não havia nenhum objeto da vítima no carro.

Após, o réu CRISTIANO CAVALHERI MARIA, assim consignou na fase policial:

"QUE não foi agredido nem desrespeitado pelos responsáveis por sua prisão. Que vieram a cidade de Vinhedo a passeio; avistaram a fazenda com o portão aberto e adentraram; que, ao tentarem sair, o portão estava trancado, então tentaram sair por uma cerca e o carro atolou. Que era ele quem dirigia o veículo Fox, o qual é propriedade de uma parente de Willian. Nega subtração de qualquer item. Informa que, dentro do veículo, havia apenas milho que pegaram na plantação da fazenda. Questionado sobre qual celular apreendido é o seu, respondeu que o de cor branca e não deu autorização para que seja vasculhado". Em Juízo, declarou que não é verdade o que consta na denúncia. Conhece os demais réus. Não é usuário de drogas. Não conhece nenhuma das testemunhas. Não havia bens da vítima dentro do veículo. Pegou milho na vegetação que havia perto do local abordado. Não se aproximaram da torre. Quando o veículo parou para o Willians fazer necessidades, saíram três indivíduos do local, um estava com mochila.

Dando continuidade, o representante da vítima A.P.S., assim relatou na fase policial:

"Que é supervisor de segurança da empresa Claro e, nesta data, recebeu uma ligação de Rodrigo, técnico de manutenção, dizendo que, ao chegar a torre de telefonia SIVINR1, percebeu que tinha pessoas estranhas próximas; que o orientou a se distanciar e fez contato com a polícia militar através do 190. Já nesta unidade policial, identificou o rádio transmissor e os cabos, apreendidos com os meliantes, como sendo da torre; já o molho de chaves, que também foi apreendido com os meliantes, reconheceu como sendo produto do roubo da data de 10/01/2022, em uma torre localizada na Avenida Sebastião Cury, 2351, no Parque Figueira, na cidade de Campinas/SP, registrado nos RDOs 79312/2022 e 119593/2022 Delegacia Eletrônica". Em Juízo, declarou que trabalha para empresa de segurança que presta serviço para a claro. Houve um furto em janeiro de um molho de chave. Em março, recebeu a ligação

de um técnico informando que havia um indivíduo em cima da torre. Foram localizados três indivíduos com bens furtados da torre, bem como encontrado o molho de chaves. Os indivíduos estavam com o carro Fox preto. Houve uma variação no sinal do sistema, motivo pelo qual o técnico compareceu a torre. Havia cabos cortados e um rádio transmissor no veículo dos furtadores. O local da torre é fechado, há um portão. O técnico informou que o portão havia sido aberto com chave. O técnico colocou outro cadeado no portão e se afastou do local.

Após, a testemunha R.A.M.N., assim esclareceu na fase policial:

“Que é da engenharia da Claro e monitora a rede; na data dos fatos, percebeu a queda de uma das células do site; deslocou-se até o site, local dos fatos e, há cerca de 500 metros, avistou um meliante, de calça escura e faixa refletiva, em cima da torre; parou em frente ao portão e ficou observando e, ao ser visto, tal indivíduo desceu imediatamente da torre. Fez contato com o supervisor e foi acionado a equipe de segurança da empresa; neste meio tempo, colocou outro cadeado por cima do cadeado do portão, que estava intacto, para evitar a fuga. Que foi solicitado que se afastasse do local e aguardou a chegada da polícia militar, para quem passou as informações. Que, após, foi até a torre com os policiais, e verificou muitos fios cortados, vários ainda pendurados, que seriam subtraídos. Que lhe foi apresentado o molho de chaves apreendido com os meliantes, as quais reconheceu como sendo da operadora Claro Móvel que tinha sido objeto de roubo no mês de janeiro”. Em Juízo, declarou que no dia 05/03 foi ao local dos fatos e identificou um indivíduo em cima da torre. Acionou a segurança. Foram encontrados 3 indivíduos. Foi localizado um molho de chaves, que foi furtado em janeiro. As chaves davam acesso às torres. Conhece o Arildo Pereira, segurança corporativo. O portão de acesso à torre foi fechado com um novo cadeado.

Na sequência, a policial militar CINTIA MARIA SANTOS DE SOUZA, assim consignou na fase policial:

“Que foram acionados via COPOM para possível furto de fios de telefonia em andamento; próximos ao local, se depararam com o técnico da Claro, que informou ter visto um indivíduo na torre e o portão fechado; que, então, usou outro cadeado no portão para evitar a fuga, e pediu que os policiais averiguassem. Informa que se aproximaram do portão e avistaram um veículo Fox enroscado no barranco entre a entrada e a saída do terreno, onde havia uma cerca que estava cortada. Que adentraram parte do terreno, pela abertura da cerca, e pôde ver no interior do veículo um indivíduo, de cutis parda, magro, de blusa escura e calça cinza com faixa refletiva verde, tentando dar partida, enquanto outro indivíduo, de cutis branca, alto e de calça e blusa cinza estava agachado tentando erguer a roda e um terceiro indivíduo, moreno e de bermuda, tentava empurrar o veículo. Que procederam à abordagem, questionaram o que estavam fazendo, tendo eles respondido que eram terceirizados, mas não souberam explicar o que estavam fazendo. Em vistoria no veículo, localizaram um rádio transmissor, um rolo de fio e outros equipamentos, bem como um molho de chaves, que foram todos apreendidos e apresentados nesta unidade. Informa que fez novo contato com o técnico para que informasse as vestes do indivíduo que tinha avistado e, diante da confirmação de que era o mesmo encontrado dentro do veículo, foi dado voz de prisão e os três indivíduos foram algemados porque ofereciam risco de fuga. Informa que, após, averiguaram o terreno e localizaram mais fios cortados, pendurados ainda, os quais não foram possíveis de serem apreendidos. Que, ainda, foi mostrado ao técnico o molho de chaves encontrado com os meliantes, tendo ele dito que acreditava ser o molho de chaves produto de roubo no mês de janeiro, por serem idênticas; tal informação foi confirmada já nesta unidade policial, por serem os códigos os mesmos acostados no RDO de roubo”. Em Juízo, declarou que foi acionada via copom para apurar possível furto em andamento. Chegando ao local, fez contato com um funcionário da Claro. Havia um carro na entrada no local. Foi colocado mais um cadeado no portão para impedir a fuga dos roubadores. Ao visualizarem o veículo, encontraram três indivíduos e bens

dentro do carro, equipamentos de radio-transmissor, luva antichoque, cinto de escalada e varias chaves. Não conhecia os réus. O local da torre é fechado com cerca e há um portão. Os réus estavam em um barranco ao lado do portão. Havia fios cortados pendurados na torre. Os réus informaram que eram funcionários terceirizados.

Por fim, o policial militar WAGNER RODILHA DE MORAIS, assim esclareceu na fase policial:

“Que foram acionados para atender ocorrência de possível furto de fios em andamento. Próximo ao local, foram informados pelo técnico de manutenção Rodrigo que havia avistado um indivíduo em cima da torre de telefonia da Claro e o portão fechado, com o cadeado intacto, tendo usado outro cadeado pra garantir que não abrisse e evitar a fuga, e acionou a polícia para averiguação; que, já naquele momento, estavam no portão tentando sair. Informa que, já no local, avistaram o veículo Fox atolado em um barranco, com um indivíduo no volante, outro tentando levantar o pneu e um terceiro tentando empurrar o veículo; que procederam à abordagem, questionados, os indivíduos alegaram que estavam no local para fazer manutenção. Que realizaram busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado e, no veículo, os equipamentos de segurança, roupas, ferramentas, fios, rádio transmissor e um molho de chaves, contendo 31 chaves. Que foi dado voz de prisão e os indivíduos foram algemados por risco de fuga e para garantir a segurança da equipe, haja vista que um dos indivíduos, Wallison, estava agitado. Que os produtos foram apreendidos e o molho de chaves, apresentado ao técnico Rodrigo, ainda no local, foi reconhecido como sendo o molho de chaves produto de roubo no mês de janeiro”.

Do Valor das Provas:

Do Depoimento do Representante da Empresa Vítima:

Não há razões para que os depoimentos prestados pelo representante da empresa vítima sejam acolhidos com reserva, já que “em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância” (TACrim – Ap. nº. 440.643-6 – 8ª Câmara – j. 23.7.86 – Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

“Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente” (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores” (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações do representante da empresa vítima.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelos acusados.

Dos Depoimentos dos Policiais Militares:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente os acusados, até porque sequer os conhecia.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Recepção:

É certo que o delito atingiu a consumação.

O depoimento do representante da empresa vítima e das testemunhas, formam o conjunto probatório que se faz suficiente e robusto para ensejar a condenação.

Na fase policial, os réus negaram a prática do delito.

No entanto, é de considerar que "na recepção, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Já se decidiu que "o dolo específico constante no art. 180, caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminoso da res, deve ser auferido através de exame de circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse

propriamente dita" (JTACRIM 33/195).

Em seu depoimento, esclareceu o representante da empresa vítima, que é supervisor de segurança. No dia dos fatos recebeu uma ligação do técnico de manutenção, dizendo que ao chegar em determinada torre, avistou pessoas estranhas. Orientou ele a se distanciar e acionou a PM. Na Delegacia de Polícia, identificou o rádio transmissor e os cabos apreendidos com os indivíduos, como sendo da torre. Já o molho de chaves, reconheceu como produto de roubo em 10/01/2022, na cidade de Campinas.

Por sua vez, a testemunha R.A.M.N., relatou que é do setor de engenharia da empresa CLARO e monitora a rede. Na data dos fatos, percebeu a queda de uma das células do site. Deslocou-se até o local e avistou um meliante de calça escura e faixa refletiva em cima da torre. Parou em frente ao portão e ficou olhando. Quando tal indivíduo lhe viu, desceu rápido da torre. Ele então acionou a equipe de segurança e colocou outro cadeado no portão para que não se evadissem, após, ficou aguardando a chegada dos policiais militares. Com a chegada dos policiais, pôde constatar diversos fios cortados e outros pendurados. Os policiais ainda lhe apresentaram um molho de chaves apreendido com os indivíduos, o qual reconheceu como sendo da operadora CLARO MÓVEL, que tinha sido objeto de roubo no mês de janeiro.

Os policiais militares esclareceram, que foram acionados pelo técnico da empresa vítima, informando que avistou um indivíduo desconhecido em cima de uma das torres da CLARO, entretanto, o portão estava fechado. Chegando ao local, conversaram com o técnico e olhando no terreno, perceberam um veículo FOX atolado e três indivíduos tentando tirá-lo do local. Questionados, disseram que eram técnicos terceirizados, mas não conseguiram explicar o que faziam no local. Olhando no interior do veículo, encontraram diversos objetos subtraídos da torre e, inclusive, um molho de chaves, o qual havia sido subtraído no mês de janeiro, conforme informações prestadas pelo representante da empresa vítima. Após, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Na fase policial os réus negaram a prática do delito. Em Juízo, também negaram estarem no local para a prática do delito.

Conforme auto de exibição e apreensão (pág. 30/31), foi apreendido com os réus o molho de chaves, o qual foi produto de roubo em 10/01/2022, na cidade de Campinas, conforme Boletim de Ocorrência (pág. 176/178, 179/181 e 182/184). Referidas chaves são utilizadas nos equipamentos constantes nas torres, sendo avaliadas em torno de R\$ 9.500,00 (pág. 168).

Frise-se que apesar dos argumentos da d. Defesa, está corroborada a materialidade do crime, estando sua versão isolada nos autos. Anoto que, diante o conjunto probatório que se formou, o ônus da prova em sentido contrario era exclusivamente sua.

Ao suscitar ser adquirente de boa-fé, é de sua incumbência comprovar essa condição, e isso não foi feito.

Esse entendimento é pacificado pelo E. Tribunal, vejamos:

"RECEPÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão, testemunhas civis e depoimento de policiais validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de

autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal." (TJSP - Apelação nº 0077670-13.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo. 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Lauro Mens de Mello. Julgado em 29/10/2015) (grifei e sublinhei).

No mais, mesmo que se tente dar credibilidade à condição de terceiro de boa-fé arguida, é certo que os conflitos existentes em suas versões deixam claro que eles tinham ciência do vício que maculava o produto. Se assim não fosse, repito, deveriam ter comprovado essa condição.

Assim, pelos fatos circunstanciais comprovados e explicitados acima, não houve imprudência, negligência ou imperícia na conduta dos réus, mas sim dolo específico ao simplesmente adquirir e transportar o bem, sem qualquer comprovação idônea de sua procedência.

Ademais, pela regra do ônus de prova, repita-se, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a justificar devidamente a posse, o que não ocorreu.

Nessa esteira:

"RECEPTAÇÃO DOLOSA - Condenação imposta com base em indícios - Admissibilidade - Desnecessidade da existência de prova robusta e inconcussa da autoria do crime - Suficiência da apreensão do veículo roubado na posse do agente, mormente se este não apresenta justificativa convincente sobre a origem da "res" (TACrimSP - RT 773/598);

Por essas razões, a condenação pelo crime de receptação encontra respaldo no caso em tela.

Do Crime de Furto Tentado:

Restou demonstrado nos autos, que os réus, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, teriam tentado subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 30 metros de cabos de energia e um rádio transmissor de telecomunicação, pertencente a empresa Claro S/A, sendo que o intento apenas não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

Em seu depoimento, esclareceu o representante da empresa vítima, que é supervisor de segurança. No dia dos fatos recebeu uma ligação do técnico de manutenção, dizendo que ao chegar em determinada torre, avistou pessoas estranhas. Orientou ele a se distanciar e acionou a PM. Na Delegacia de Polícia, identificou o rádio transmissor e os cabos apreendidos com os indivíduos, como sendo da torre. Já o molho de chaves, reconheceu como produto de roubo em 10/01/2022, na cidade de Campinas.

Por sua vez, a testemunha R.A.M.N., relatou que é do setor de engenharia da empresa CLARO e monitora a rede. Na data dos fatos, percebeu a queda de uma das células do site. Deslocou-se até o local e avistou um meliante de calça escura e faixa refletiva em cima da torre. Parou em frente ao portão e ficou olhando. Quando tal indivíduo lhe viu, desceu rápido da torre. Ele então acionou a equipe de segurança e colocou outro cadeado no portão para que não se evadissem, após, ficou aguardando a chegada os policiais militares. Com a chegada dos policiais, pôde constatar diversos fios cortados e outros pendurados. Os policiais ainda lhe apresentaram um molho de chaves apreendido com os indivíduos, o qual reconheceu como sendo da operadora CLARO MÓVEL, que tinha sido objeto de roubo no mês de janeiro.

Os policiais militares esclareceram, que foram acionados pelo técnico da empresa vítima, informando que avistou um indivíduo desconhecido em cima de uma das torres

da CLARO, entretanto, o portão estava fechado. Chegando ao local, conversaram com o técnico e olhando no terreno, perceberam um veículo FOX atolado e três indivíduos tentando tirá-lo do local. Questionados, disseram que eram técnicos terceirizados, mas não conseguiram explicar o que faziam no local. Olhando no interior do veículo, encontraram diversos objetos subtraídos da torre e, inclusive, um molho de chaves, o qual havia sido subtraído no mês de janeiro, conforme informações prestadas pelo representante da empresa vítima. Após, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Os réus negaram a prática do delito.

Mas, apesar do quanto argumentado pelos réus, suas versões restaram isoladas nos autos. Ademais, o representante da empresa vítima, a testemunha presencial e os policiais militares não teriam qualquer motivo para incriminá-los. Portanto, cabia aos réus, provar suas versões, fato do qual não se desincumbiram, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

O delito apenas não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo em vista que foram surpreendidos pelo técnico da empresa CLARO, o qual acionou a polícia militar. Os indivíduos tentaram fugir, mas o veículo deles ficou atolado. Nesse tempo, os policiais chegaram e eles foram detidos.

Diante do exposto, restou comprovada a materialidade do crime de furto, bem como a autoria dos réus.

Das Qualificadoras:

Do Rompimento de Obstáculo:

Conforme constou na denúncia, os réus teriam adentrado no local mediante rompimento de obstáculo.

O artigo 171 do Código de Processo Penal exige perícia no local, para comprovar o rompimento.

O laudo pericial do local dos fatos (pág. 339/344), demonstra que a torre fica localizada numa propriedade rural, sendo cercada por muro de alvenaria e arame farpado em seu topo.

Nas proximidades do local, existe uma cerca, para impedir a passagem de veículos e pedestres. Entretanto, conforme relato das testemunhas, o veículo adentrou por esta cerca, a qual foi rompida para que eles tivessem passagem (pág. 344). Ocorre, que quando tentavam fugir do local, o veículo FOX acabou atolando e quando os policiais chegaram no local, os três estavam tentando tirar o veículo de lá.

A prova oral em consonância com a prova pericial é robusta no sentido de constatar a qualificadora de rompimento de obstáculo, nesse sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. FURTO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA. REGIME ABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação,

ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgRED/SP - Rel. Min. Celso de Mello - j. 31.05.2011; AI 814.640/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 02.12.2010; HC 92.020/DF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 21.09.2010; HC 101.911/RS - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.05.2010; HC 94.384/RS - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 13.06.2007; HC 98.814/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 23.06.2009; HC 94.243/SP - Rel. Min. Eros Grau - j. 31.03.2009; HC 96.517/RS - Rel. Min. Menezes Direito - j. 03.02.2009; RE 360.037/SC - Rel. Min. Cezar Peluso - j. 07.08.2007; HC 75.385/SP - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 07.10.1997). 2. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes de furto e de corrupção de menor. 3. Caso concreto indica o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC 156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrição interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC Voto n. 7.282 - Apelação n. 0083644-94.2014.8.26.0050 4 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10). 5. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. As qualificadoras previstas no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, estão presentes, tendo sido atestadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como pelo laudo pericial realizado no terreno. 6. Furto tentado. Reconhecimento da tentativa do crime, considerando o "iter criminis" percorrido, sem atingir a tão desejada consumação engendrada pelo agente. 7. Corrupção de menores. Crime formal. Precedentes STF (RHC 111.434/DF 1ª T. Rel. Min. Cármen Lúcia

j. 03.04.2012 DJU 17.04.2012; RHC 111.137/DF 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux j. 14.02.2012 DJU 15.03.2012; RHC 107.623/DF 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes j. 26.04.2011 DJU 25.05.2011; RHC 106.364/DF 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14.12.2010 DJU 11.02.2011). Precedentes STJ (AgRg no REsp 1.371.942/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.05.2013 DJU 11.06.2013; AgRg no REsp 1.357.397/DF 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes j. 19.03.2013 DJU 05.04.2013; HC 224.770/DF 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 05.03.2013 DJU 12.03.2013; EDcl no AGRg no REsp 1.3412.726/SP 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 20.11.2012 DJU 27.11.2012; AgRg no REsp 1.254.739/RS 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 13.03.2012 DJU 29.03.2012; HC 203.036/DF 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp j. 27.09.2011 DJU 14.10.2011) e Súmula n. 500 do STJ. 8. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 9. Corrupção de menores. Concurso Formal. Precedentes da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (Ap. Crim. n. 0004368-12.2014.8.26.0083 Rel. Des. Geraldo Wohlers 3ª Câmara de Direito Criminal j. 02.08.2016 - Dje. 03.08.2016; Ap. Crim. n. 0004402-29.2014.8.26.0554 Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso 3ª Câmara de Direito Criminal j. 26.07.2016 Dje. 26.07.2016; Ap. Crim. n. 0002644-78.2015.8.26.0554 Rel. Des. Cesar Mecchi Morales - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 19.07.2016 Dje 19.07.2016; Ap. n. 0008044-72.2011.8.26.0438 Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 20.10.2015 Dje. 22.10.2015 e Ap. Crim. n. 3006254-22.2013.8.26.0344 - Rel. Des. Luiz Toloza Neto - 3ª Câmara de Direito Criminal - j. 24.03.2015 - Dje. 25.03.2015). A propósito, ressalvo a minha posição, porque a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal assentou o entendimento que entre os dois crimes, como no caso em tela, aplica-se a regra do concurso formal, nada obstante, para mim, haver-se-ia de reconhecer o concurso material entre o crime de furto e o crime de corrupção de menor. Assim, com arrimo no princípio da colegialidade, e a fim de racionalizar o julgamento das apelações criminais, adiro ao entendimento prevalente da Câmara julgadora e reconheço o concurso formal entre os crimes, anotando-se que este não representa o meu entendimento, que é aquele que reconhece o concurso material entre os crimes de que se está a tratar. 10. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 11. Dosimetria da pena alterada. 12. Pena-base do crime de corrupção de menor fixada no mínimo legal. 13. Pena-base do crime de furto fixada no mínimo e mantida por ausência de recurso Ministerial. 14. Inviabilidade de redução abaixo do piso legal pela atenuante da menoridade relativa (Súmula n. 231, do STJ). 15. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menor que levaram à diminuição da pena. 16. Regime aberto mantido. 17. Réu que fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porque preencheu os requisitos legais do art. 44, do Código Penal. 18. Recurso parcialmente provido. (Apelação - 0083644-94.2014.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Dje 14/11/2017).

Sendo assim, e considerando as provas dos autos, restou demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Do Concurso de Agentes:

Embora não tenha sido tipificado na denúncia, restou descrito, que os réus, agiram em concurso de pessoas e unidade de desígnios. E o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (artigo 383 do Código de Processo Penal).

Conforme os depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo, restou mais do que demonstrado que três indivíduos participaram do crime em questão.

Em seus depoimentos, esclareceu o técnico da empresa CLARO, que ao se aproximar da torre, visualizou um indivíduo estranho em cima da torre, o qual desceu ao vê-lo. Após a chegada da polícia militar, constatou-se três indivíduos tentando fugir do

local, com o veículo FOX, na posse dos objetos subtraídos.

Portanto, pelo menos três indivíduos participaram do delito em questão.

Com a participação de mais de um furtador houve distribuição de tarefas e tal fato tornou mais fácil e ágil a conduta dos criminosos.

Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).

Em caso semelhante, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na consecução do objetivo comum” (Apelação nº 0500047-68.2010.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em 29/09/2011).

É de se destacar que:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de sua conduta, previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unidade de crime e pluralidade de agentes” (RT 726/555);

TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monista que o nosso direito Penal perfilhou” (RT 558/309.).

Sendo assim, restou demonstrada a qualificadora do concurso de agentes, conforme previsto no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal.

Passo à Dosimetria das Penas:

Réu WILLIANS FAGUNDES:

Do Crime de Furto:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente em duas condenações, sendo que uma delas será utilizada como MAUS ANTECEDENTES, em decorrência da condenação por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, processo n.º 0008142-93.2014.8.26.0198, que tramitou perante a Vara Criminal de Franco da Rocha, com trânsito em julgado para a defesa em 15/12/2016, estando em cumprimento do livramento condicional, conforme certidão de objeto e pé (pág. 208/211). Além disso, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo uma dessas causas suficiente para qualificar o delito, e a outra será considerada como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, resultando em: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 208/211), em decorrência da condenação anterior por receptação, processo n.º 0003879-86.2012.8.26.0198, que tramitou perante a Vara

Criminal de Franco da Rocha, com trânsito em julgado em 21/06/2016, com início do cumprimento da pena em 20/09/2017, sem informação da extinção pelo cumprimento, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, resultando em: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista que o crime de furto somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que ele foi flagrado pelo técnico da empresa vítima, o qual acionou a polícia militar, considerando-se que o crime, em muito, se aproximou do crime consumado, reduzo a pena no mínimo (1/3), resultando em: 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Crime de Recepção:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente em duas condenações, sendo que uma delas será utilizada como MAUS ANTECEDENTES, em decorrência da condenação por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, processo n.º 0008142-93.2014.8.26.0198, que tramitou perante a Vara Criminal de Franco da Rocha, com trânsito em julgado para a defesa em 15/12/2016, estando em cumprimento do livramento condicional, conforme certidão de objeto e pé (pág. 208/211), razão pela qual, majoro a pena em 1/6, resultando em: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 208/211), que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO (em decorrência da condenação anterior por receptação, processo n.º 0003879-86.2012.8.26.0198, que tramitou perante a Vara Criminal de Franco da Rocha, com trânsito em julgado em 21/06/2016, com início do cumprimento da pena em 20/09/2017, sem informação da extinção pelo cumprimento), fato que agrava ainda mais a situação, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, resultando em: 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que "atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo". Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que "a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica".

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, "na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza'".

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada". (HC 101918/MS - Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)".

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

A réu é REINCIDENTE, com condenações anteriores por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, posse de arma de fogo e receptação, conforme certidão de objeto e pé (pág. 208/211), razão pela qual, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento das penas no regime FECHADO.

Nesse sentido recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - Na hipótese, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, "a", e parágrafo 3º do Código Penal.(...)" (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Réu CRISTIANO CAVALHERI MARIA:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59